

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 551/2546	พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	เด็กหญิง ท. กับพวก โดยนาง จ. ผู้แทน	
	เฉพาะคดี	
	นาย นิวัฒน์ คัสโส	โจทก์
		จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 91, มาตรา 277 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ร่วมทั้งสองเบิกความมีรายละเอียดขณะถูกจำเลยกระทำชำเราค่อนข้างชัดเจนเกินกว่าที่โจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งเป็นเด็กจะสามารถแต่งเรื่องขึ้นเองหรือแม้แต่การเลี่ยมสอนโดยเฉพาะที่โจทก์ร่วมที่ 2 อ้างการถูกร่วมเพศทางทวารหนักจำเลยเป็นผู้เลี่ยมดูโจทก์ร่วมทั้งสองมานานหลายปีถือว่าเป็นผู้มีพระคุณ หากไม่เป็นความจริงโจทก์ร่วมทั้งสองคงไม่กล้าสร้างเรื่องมาใส่ร้ายจำเลย ทั้ง ส. ศ. และ พ. ชาวบ้านหมู่เดียวกับจำเลยซึ่งไม่มีสาเหตุกับจำเลยมาก่อนก็ยืนยันถึงพฤติกรรมจำเลยที่เคยแอบเห็นจำเลยกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 2 ทางทวารหนัก แม้จะระบุเวลาคลาดเคลื่อนจากที่โจทก์ร่วมที่ 2 ระบุ ประมาณ 2 เดือน ก็มีข้อพิรุธเพราะโจทก์ร่วมที่ 2 ถูกจำเลยกระทำชำเรากว่า 10 ครั้งการที่จำเลยอ้างว่าช่วงเวลาเกิดเหตุตามฟ้องเป็นเวลากลางวันทั้งสิ้นนั้น ก็หาเป็นเรื่องผิดปกติไม่เพราะจำเลยมีภริยาอยู่จึงต้องอาศัยโอกาส ทั้งสถานที่ที่โจทก์ร่วมทั้งสองถูกร่วมกระทำมักจะเป็นที่ลับตา เช่น ในป่า หรือเถียงนา ส่วนที่โจทก์ร่วมทั้งสองไม่เรียกร้องขอความเป็นธรรมมาแต่แรกก็เป็นเพราะ

ต้องพักอาศัยอยู่กับจำเลย ประกอบกับโจทก์ร่วมทั้งสองยังเป็นเด็กและถูกข่มขู่ด้วย
ดังนั้น จากพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองเท่าที่นำสืบมาจึงมีน้ำหนัก
เชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดฐานกระทำชำเราและพยายามกระทำชำเราโจทก์ร่วมทั้งสอง
จริง

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ระบุว่าโทษจำคุก
อย่างสูงถึง 20 ปี การกระทำความผิดของจำเลยทุกกระทงมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูง
จึงเกิน 10 ปี ทั้งความผิดของจำเลยเป็นการกระทำต่อโจทก์ร่วมสองคนต่างวันเวลา
และสถานที่ถือว่าต่างกรรมต่างวาระ ซึ่งแม้จะเป็นความผิดอย่างเดียวกันแต่ก็ไม่
เกี่ยวพันกันกรณีไม่อยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(2) จึงนำโทษ
ที่จำเลยได้รับจริงทุกกระทงมารวมแล้วเกิน 20 ปี ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำชำเราเด็กหญิง ท. ผู้เสียหายที่ 1 อายุ 11 ปีเศษซึ่ง
เป็นเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 13 ปี และมีใช้ภริยาของจำเลย โดยจำเลยใช้กำลัง
ประทุษร้าย จนทำให้ผู้เสียหายที่ 1 อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ แล้วจำเลย
กระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 จนจำเลยสำเร็จความใคร่รวม 5 ครั้ง โดยผู้เสียหายที่ 1
ไม่ยินยอมและจำเลยกระทำชำเราเด็กหญิง ม. ผู้เสียหายที่ 2 อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเด็ก
หญิงอายุไม่เกิน 13 ปี และมีใช้ภริยาของจำเลย โดยจำเลยใช้กำลังประทุษร้ายจน
ทำให้ผู้เสียหายที่ 2 อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ แล้วจำเลยกระทำชำเราผู้เสีย
หายที่ 2 จนจำเลยสำเร็จความใคร่รวม 2 ครั้ง โดยผู้เสียหายที่ 2 ไม่ยินยอมขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 276, 277

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาเด็กหญิง ท. และเด็กหญิง ม. ผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ยื่น
คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
277 วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุก
กรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทง
ละ 7 ปี รวม 7 กระทง เป็นจำคุก 49 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นตั้งผู้
แทนเฉพาะคดีให้โจทก์ร่วมทั้งสอง และให้ผู้แทนเฉพาะคดีตั้งนายเสถียร ภูติโสทนนาย
โจทก์ร่วมทั้งสองคนเดิมเสียใหม่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถของโจทก์
ร่วมทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 56 วรรคสี่ ประกอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6, 15 ตามรายงานกระบวนการ
พิจารณาลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วตั้งนาง จ. น้าโจทก์ร่วม
ทั้งสองเป็นผู้แทนเฉพาะคดีโจทก์ร่วมทั้งสอง และนาง จ. แต่งนายเสถียรเป็นทนาย
โจทก์ร่วมทั้งสองใหม่แล้ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานกระทำชำเราเด็ก
หญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปี รวม 6 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 7 ปี และมีความ
ผิดฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 80 ลงโทษจำคุก 4 ปี 8 เดือน
รวมเป็นจำคุก 46 ปี 8 เดือน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นที่ยุติว่า โจทก์ร่วมทั้งสองเป็นพี่น้องกัน เมื่อบิดามารดาถึงแก่ความตาย โจทก์ร่วมทั้งสองได้ไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวของนาง ค. ซึ่งเป็นพี่สาวของบิดาโจทก์ร่วมทั้งสอง จำเลยเป็นสามีของนาง ค. ช่วงเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 1 มีอายุ 11 ปีเศษ ส่วนโจทก์ร่วมที่ 2 มีอายุ 10 ปีเศษ คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองมีตัวโจทก์ร่วมทั้งสองมาเบิกความเป็นประจักษ์พยานว่า โจทก์ร่วมทั้งสองถูกจำเลยกระทำชำเรากว่า 10 ครั้ง แต่เท่าที่โจทก์ร่วมที่ 1 จำได้ครั้งแรกคือเมื่อเดือนเมษายน 2538 ที่ริมหนองน้ำ ครั้งที่สองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2538 ที่ในป่าโดยถูกนาง ค. ซึ่งเป็นภริยาจำเลยบังคับให้ไปตัดฟันกับจำเลย ครั้งที่สามเมื่อเดือนมิถุนายน 2538 ขณะตามจำเลยไปตัดไม้ไผ่เพื่อทำดอกมัดข้าว ครั้งที่สี่เมื่อเดือนมกราคม 2539 นาง ค. สั่งให้ตามจำเลยไปตัดไม้มาทำหลักล้อมรั้ว และครั้งที่ห้าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2539 จำเลยเรียกให้ขึ้นไปบนบ้านและกระซอกเข้าไปกระทำชำเราอยู่ที่นอนของจำเลย ส่วนโจทก์ร่วมที่ 2 เท่าที่จำได้มี 2 ครั้งครั้งแรกคือ เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2539 เวลากลางวัน ขณะไปเกี่ยวข้าวกับจำเลยที่ทุ่งนา จำเลยได้เรียกโจทก์ร่วมที่ 2 ขึ้นไปกระทำชำเราบนเถียงนา แต่ไม่สำเร็จไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปได้ จึงเปลี่ยนเป็นร่วมเพศทางทวารหนัก และที่จำได้อีกครั้งเมื่อเดือนมกราคม 2540 เวลากลางวัน ขณะไปดักหนูกับจำเลยที่ทุ่งนาจำเลยกระทำชำเราสำเร็จ ครั้นวันที่ 24 สิงหาคม 2540 นาง ค. ดีและขับไล่โจทก์ร่วมทั้งสองจึงไปพักอยู่ที่บ้านเดิมของบิดามารดาซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 20 เมตรในคั้นนั้นเวลาประมาณ 23 นาฬิกา จำเลยมาดับไฟที่บ้านดังกล่าว โจทก์ร่วมทั้งสองกลัวว่าจำเลยจะมากกระทำชำเรา จึงพากันหนีไปขออาศัยที่บ้านนาง จ. ซึ่งเป็นน้องของโจทก์ร่วมทั้งสองก่อนที่จะเล่าให้นาง จ. ฟังเรื่องที่ถูkjจำเลยกระทำชำเราในวันรุ่งขึ้นโดยมีนาย ส. นาย ศ. และ นาย พ. ซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านเดียวกับจำเลยมา

เบิกความสนับสนุนว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2540 เวลาประมาณ 17 นาฬิกา ขณะทั้งสามคนพากันไปตกเบ็ดที่ริมห้วยด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ได้เห็นจำเลยกำลังกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 2 ทางด้านหลัง และมีร้อยตำรวจโทกมลรัตน์ พาน้อย พนักงานสอบสวนมาเบิกความว่าชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับว่าพยายามกระทำชำเรา ฝ่ายจำเลยมีตัวจำเลยและนาง ค. ภริยาจำเลยซึ่งเป็นป้าของโจทก์ร่วมทั้งสองมานำสืบต่อสู่ว่า รับโจทก์ร่วมทั้งสองมาพักอาศัยอยู่ด้วยเมื่อโจทก์ร่วมที่ 1 มีอายุเพียง 3 ปี หลังจากที่บิดามารดาโจทก์ร่วมทั้งสองถูกคนร้ายฆ่าตายพร้อมกัน โดยแลกกับการได้ทำนาในที่ดินของบิดามารดาโจทก์ร่วม ทั้งสองให้ความรักและการศึกษาแก่โจทก์ร่วมทั้งสองเสมือนบุตรก่อนเกิดเหตุคดีนี้นาง จ. ต้องการให้โจทก์ร่วมทั้งสองไปอยู่ด้วยแต่นาง ค. ไม่ยินยอม นอกจากนี้ยังมีปัญหาขัดแย้งกันด้วยเรื่องที่ดินทั้งสองฝ่ายต่างแย่งกันที่จะจัดทำบุญอุทิศกุศลให้บิดามารดาของโจทก์ร่วมทั้งสอง เหตุที่จำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวนเพราะกลัวถูกทำร้ายและพนักงานสอบสวนหลอกว่าโทษน้อยหากต่อสู้คดีก็ไม่มีทางชนะเนื่องจากโจทก์ร่วมทั้งสองเป็นเด็ก โดยมีนาง พ. ย่าของโจทก์ร่วมทั้งสอง และนาง ร. เพื่อนบ้าน และนาย บ. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 มาเบิกความสนับสนุนสรุปว่าจำเลยเป็นคนดี โจทก์ร่วมทั้งสองมีความร่าเริง ไม่มีท่าทีของคนที่ถูกข่มขืน เห็นว่า โจทก์ร่วมทั้งสองเบิกความมีรายละเอียดขณะถูกจำเลยกระทำชำเราก่อนข้างขัดแย้งเกินกว่าที่โจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งยังเป็นเด็กจะสามารถแต่งเรื่องขึ้นได้เองหรือแม้แต่การเสียมสอน โดยเฉพาะที่โจทก์ร่วมที่ 2 อ้างการถูกร่วมเพศทางทวารหนัก จำเลยและนาง ค. เลี้ยงดูโจทก์ร่วมทั้งสองนานหลายปี ถือเป็นผู้มีพระคุณ หากไม่เป็นความจริงโจทก์ร่วมทั้งสองคนไม่กล้าที่จะสร้างเรื่องมาใส่ร้ายจำเลย ข้อขัดแย้งระหว่างนาง จ. กับครอบครัวจำเลยตามที่จำเลยนำสืบต่อสู้อย่างไรในเรื่องที่นาง จ. ประสงค์จะรับโจทก์ร่วมทั้งสองไปเลี้ยงดู หรือเรื่องที่ว่าแย่งกันจัดทำบุญอุทิศกุศลให้บิดามารดาโจทก์ร่วมทั้งสอง ถึงหากจะเป็นจริง ก็เป็นเรื่องการไม่พอใจกันธรรมดา ทั้งไม่ใช่เรื่องที่จะถึงกับทำให้โจทก์ร่วมทั้งสองที่เป็นเด็กกล้าสร้าง

เรื่องขึ้นมาปรักปรำจำเลย และก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอีกด้วย เพราะหลังเกิดเหตุ โจทก์ร่วมทั้งสองก็ไม่ได้พักอยู่กับนาง จ. หากแต่อยู่กับนาง จ. ผู้แทนเฉพาะคดีของ โจทก์ร่วมทั้งสอง ที่สำคัญคือโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองยังมีนาย ส. นาย ศ. และ นาย พ. ซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่เดียวกับจำเลย และไม่ปรากฏมีสาเหตุใดกับจำเลยมา ยืนยันถึงพฤติกรรมของจำเลย ว่า เคยแอบเห็นจำเลยกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 2 ทาง ทวารหนัก แม้จะระบุเป็นเดือนมีนาคม 2540 ซึ่งต่างจากที่โจทก์ร่วมที่ 2 ว่าเป็น เดือนมกราคม 2540 ก็ไม่ใช่ข้อที่จะเป็นพิรุธ เนื่องจากโจทก์ร่วมที่ 2 เบิกความแล้ว ว่าความจริงถูกจำเลยกระทำชำเรากว่า 10 ครั้ง ที่จำเลยฎีกาอ้างว่าตามคำเบิกความ ของโจทก์ร่วมทั้งสองแสดงว่าเหตุเกิดกลางวันทั้งสิ้นจึงเป็นเรื่องที่ผิดปรกติเพราะอาจ มีผู้รู้เห็นโดยง่ายก็หาใช่เป็นการผิดปรกติไม่ เพราะจำเลยมีภริยาอยู่แล้ว จึงต้อง อาศัยโอกาส โจทก์ร่วมทั้งสองเบิกความเป็นเหตุผลว่า สถานที่ที่ถูกระทำมักจะเป็น ที่ลับตา คือที่ในป่าบ้าง ที่ในเถียงนาบ้าง ส่วนที่ว่าเหตุใดโจทก์ร่วมทั้งสองไม่เรียก ร้องขอความเป็นธรรมมาแต่แรก ก็น่าจะเป็นเพราะโจทก์ร่วมทั้งสองพักอาศัยอยู่กับ จำเลย ประกอบกับเป็นเด็กและถูกขู่ สรุปลแล้วศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานของ โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองเท่าที่นำสืบมีน้ำหนักเชื่อว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานกระทำ ชำเราและฐานพยายามกระทำชำเราอันเป็นความผิดหลายกรรมดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษาจริง

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในประการสุดท้ายว่า ความผิด ของจำเลยต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(2) ที่จะลงโทษจำคุกทุก กระทั่งรวมกันต้องไม่เกิน 20 ปี หรือไม่ เห็นว่า ความผิดตามมาตรา 277 วรรคสอง ระวังโทษจำคุกอย่างสูงถึง 20 ปี การกระทำความผิดของจำเลยทุกกระทงมีอัตรา โทษจำคุกอย่างสูงจึงเกิน 10 ปี ทั้งความผิดของจำเลยเป็นการกระทำต่อโจทก์ร่วม สองคนโดยกระทำต่างวันเวลาและสถานที่ถือว่าต่างกรรมต่างวาระที่แม้จะกระทำ ความผิดอย่างเดียวกันแต่ก็ไม่เกี่ยวพันกัน กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 91(2) และไม่อาจนำโทษจำคุกที่จำเลยต้องรับจริงทุกกระทงมารวมแล้วไม่เกิน20 ปี ดังที่จำเลยอ้างในฎีกาได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา นั้น เห็นว่า โทษจำคุกแต่ละกระทงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 กำหนดไว้ เป็นอัตราโทษขั้นต่ำสุดตามกฎหมายแล้ว จึงลดโทษจำคุกลงอีกไม่ได้ ฎีกาของจำเลย ล้วนฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เกรียงชัย จิงจตุรพิธ-วิชัย วิวิตเสวี-สำรวจ อุดมทวี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>